

1502882-02.2022.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/12/2022

... (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502882-02.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502882-02.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2238939/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 27138514 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2238939 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGER MOREIRA BASTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

ROGER MOREIRA BASTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 31 de agosto de 2022, por volta das 18h40min, na via pública da Rua Joaquim Guimarães, proximidades do número 61, bairro Jardim São Pedro, nesta cidade e comarca de Limeira, o acusado, em atividade de tráfico ilícito de entorpecentes, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para serem entregues ao consumo de terceiros, 10 porções de maconha, pesando cerca de 43 gramas, e 117 porções de cocaína, pesando cerca de 105g, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão e laudo definitivo).

Segundo apurado, no dia dos fatos, o denunciado trazia consigo, guardava e tinha em depósito as sobreditas substâncias para fins de comercialização.

Ocorre que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o denunciado, o qual, ao perceber a presença da viatura, tentou disfarçar sua presença no local, se aproximando de um popular, após o que danificou o seu aparelho celular, caracterizando, assim, a fundada suspeita e justificando a realização da abordagem.

Efetuada revista pessoal, foi apreendido em poder de ROGER um saco plástico contendo 42 porções de cocaína, bem como a quantia de R\$1.180,00 em notas trocadas.

Ato contínuo, os milicianos verificaram o local onde o denunciado foi inicialmente visto pela guarnição, localizando no poste de energia uma sacola contendo outras 75 porções da mesma substância, embaladas de forma idêntica às apreendidas em poder do denunciado e, ainda, 10 porções de maconha.

Oferecida a denúncia, determinou-se a notificação do acusado para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 128/132).

A denúncia foi recebida em 13 de outubro de 2022 (fls. 136/137).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, com interrogatório do acusado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 162/169) e da Defesa (fls. 173/185).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo pericial com resultado positivo para maconha e cocaína (fls. 105/107), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Em solo policial, o denunciado sustentou que a droga não pertencia a ele. Disse que havia ido comprar refrigerante, quando foi surpreendido por policiais militares. Alega que os agentes públicos, durante revista pessoal, derrubaram o seu aparelho celular, que veio a ser danificado. Diz que foi abordado juntamente com seu amigo Murilo, o qual foi dispensado do procedimento de averiguação. Durante as buscas na região onde foi abordado, foram encontradas as drogas, tendo os policiais a ele relacionado a propriedade dos entorpecentes (fls. 07).

Em Juízo, o réu disse que tem 32 anos. É motoboy. Estava na casa da sua namorada. Recebeu dinheiro de um grupo de entrega, é dinheiro do mês inteiro. Recebe dez reais por restaurante e por motoboy por mês. É um grupo de aplicativo, havia mais de duzentas pessoas cadastradas. Tinha recebido mil e duzentos reais no dia anterior. Pagou algumas contas. Seu aluguel vence no dia dez. Comentou com sua namorada. Teve que buscar a filha dela na escola. Ficou na casa e estava ao lado delas. A namorada iria fazer o jantar. Saiu para ir ao mercado. Encontrou com Murilo e o cumprimentou. Saiu do mercado com o refrigerante, havia pago o rapaz do

estabelecimento. Foram abordados. Não tentou se desvencilhar da abordagem. Os policiais queriam saber se ele tinha envolvimento com o tráfico. Disse que sim, já pagou sua pena. Contribuiu com a abordagem policial. Murilo afirmou que estava no ponto de tráfico e confirmou aos guardas que estava traficando. As drogas não foram encontradas no poste, mas em um carro abandonado. Os policiais falaram que não queriam Murilo, porque não iria dar nada. Tinha o celular, refrigerante e dinheiro em seu poder quando foi abordado. Não tinha entorpecentes em sua posse. Não viu o momento exato do encontro das drogas pelos guardas. Ficou na casa da namorada o dia todo. Explicou que ficou com o dinheiro do aluguel na carteira e não vê qualquer anormalidade em andar com essa quantia. Não conhecia os policiais até então. Tem até uma empresa em aberto em seu nome. Ouviu falar que ali no bairro tem ponto de tráfico, mas achou que era mais para a região do campo. Conhecia Murilo, mas não sabia que ele estava no tráfico naquele dia. Não jogou celular contra a parede e nem ficou com pacote de droga nas mãos (mídia).

Sua versão não convence.

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos seus interesses.

O policial militar João Carlos de Oliveira Junior contou que estava em patrulhamento de rotina, quando pela Rua Joaquim Guimarães, tratando-se de local conhecido como ponto de venda de drogas, depararam com o acusado, que agiu de forma suspeita, pois, estava parado naquela localidade. Assim que percebeu a aproximação da viatura, o réu colocou-se em movimento, indo em direção a um transeunte, simulando que estavam juntos. O acusado jogou o próprio celular que tinha em mãos, com muita força, danificando de forma proposital o aparelho. Ambos os indivíduos foram abordados e o popular liberado após ser revistado. Durante busca pessoal localizou nas mãos do imputado um saco plástico que continha em seu interior 42 flaconetes plásticos com cocaína e no bolso da bermuda a quantia de R\$1.180,00 (mil cento e oitenta reais) em notas trocadas. Ao verificar o local onde o acusado estava parado, o soldado Allan localizou no poste padrão de energia uma sacola com 75 flaconetes plásticos com cocaína, idênticos aos que haviam sido localizados anteriormente, e mais 10 invólucros plásticos com maconha. Questionado, ele nada declarou. Não o conhecia até então. O réu arremessou o celular e ficou com a sacola em mãos, a abordagem policial foi muito rápida, acredita que ele não se desvencilhou daquilo que tinha em mãos porque não deu tempo. Uma moça na região chamou o soldado Allan, era a namorada do acusado. Ela se chama Tamira e nada presenciou, ela só apareceu depois do ocorrido. Só abordou o indivíduo que estava junto com o acusado por segurança da equipe, foi o réu quem agiu de forma suspeita. A pessoa que foi liberada só passava pelo local, nem foi identificada, foi liberada de pronto por não ter qualquer relação com os fatos. A distância entre o quadro de energia e o local da abordagem é de dois metros de distância (mídia).

O policial militar Allan Danilo de Souza Oliveira disse que estava em patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado, o qual estava sozinho, parado na frente do imóvel de uma rua. Assim que percebeu a aproximação da viatura policial, o acusado foi em direção a um popular e jogou o próprio celular com muita força contra uma parede, danificando propositalmente o aparelho. Ambos os indivíduos foram abordados e com o popular nada de ilícito foi localizado, sendo liberado. Com o acusado localizou em suas mãos um saco plástico com 42 flaconetes plásticos contendo cocaína e no bolso da bermuda localizou a quantia de R\$1.180,00 (mil cento e oitenta reais) em dinheiro trocado. Ao verificar o local onde Roger estava parado, localizou no poste padrão de energia uma sacola com 75 flaconetes plásticos com cocaína, idênticos aos que haviam sido localizados anteriormente com Roger, e mais 10 invólucros plásticos com maconha. Indagado, o acusado nada disse. Não o conhecia. Uma moça o chamou e se identificou como Tamira, namorada do acusado. Repassou a situação a ela relativa à prisão do seu namorado. Percebeu que o transeunte só passava pelo local da abordagem, por isso ele foi liberado. Em momento algum viu a namorada do réu na rua, ela só compareceu depois

ao perceber a presença da viatura policial. O réu dispensou apenas o aparelho celular. Não sabe o motivo dele ter jogado o celular e ter ficado com as drogas em seu poder. A distância entre o poste e o local da abordagem é de dois metros. Não sabe o nome do rapaz que foi dispensado (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais militares neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o réu.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

“(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, “a priori”, valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais “lato sensu”. Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Foram ouvidas duas testemunhas de defesa.

A testemunha Tamyra Giroto Manfré disse que é namorada do acusado. Foi ouvida como informante. Seu namorado saiu para ir ao mercado. Ao sair no portão posteriormente viu um monte de policial e duas pessoas abordadas. Saiu para ver o que ocorria. Viu que seu namorado foi preso. Fazia um mês que namorava o réu. Sabe que seu namorado foi envolvido com drogas, mas ultimamente ele trabalhava e não tinha qualquer envolvimento com o tráfico. Perto da sua casa tem biqueira e o tempo todo o denunciado ficava dentro da sua casa. O rapaz que foi abordado junto com o réu se chama Murilo e falou o tempo todo que as drogas eram dele. Ficou sabendo que Murilo era menor de idade. Viu os policiais encontrando entorpecentes no poste de energia. O réu não tinha nada em seu poder. O dinheiro encontrado era para efetuar pagamento de aluguel. Nesse dia, ela não estava muito bem e o acusado ficou em sua companhia o dia todo. Viu ele sentado no chão durante a abordagem, mas não viu o momento inicial. Não tem amizade com Thais, ela mora perto da sua residência. Foi advertida a respeito da quebra de incomunicabilidade com a testemunha Thais durante o ato processual realizado (mídia).

A testemunha Thais Gomes dos Santos foi ouvida como informante em razão da quebra de incomunicabilidade ocorrida quando da oitiva da testemunha Tamyra. Não tem amizade íntima com o acusado. Viu o réu subindo, pois ele havia saído da casa de Tamyra e estava indo ao mercado. O denunciado e o adolescente foram enquadrados. Viu que tinha um automóvel abandonado na rua. Os guardas saíram com uma sacola. Não

ouviu o que era falado. A namorada do réu também saiu. O réu não tem envolvimento com o tráfico. Nunca viu ele vendendo drogas. Ficou sabendo da apreensão de Murilo. A abordagem policial foi rápida, acredita que o acusado e o adolescente não se conheciam (mídia).

Pelo teor da prova oral colhida, policiais militares faziam patrulhamento de rotina na Rua Joaquim Guimarães, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando se depararam com o acusado Roger que, ao avistar a viatura policial, tentou disfarçar a sua presença com um transeunte que ali passava, momento em que arremessou o seu telefone celular contra um muro, danificando-o por completo.

Devido a essa atitude, os policiais, em razão da fundada suspeita, decidiram abordar o denunciado e a pessoa com quem transitava, tendo sido liberado o transeunte após nada ilícito ser localizado. Ao realizarem o procedimento de revista, os agentes públicos localizaram na posse do acusado um saco plástico que continha no seu interior 42 porções de cocaína e R\$1.180,00 em espécie no bolso da bermuda.

Em seguida, os milicianos verificaram o local onde avistaram o réu de início, região onde foi encontrada mais uma sacola que continha no seu interior 75 porções contendo cocaína, idênticas ao que foi encontrado com o denunciado, mais a quantia de 10 porções de maconha.

Dessa forma, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico, haja vista a quantidade, natureza, diversidade e forma como estavam embaladas as drogas (maconha e cocaína), a conduta do acusado quando da prisão, as circunstâncias e o local da abordagem, o depoimento incriminador dos policiais militares, o encontro de dinheiro sem justificativa e os antecedentes específicos na traficância ilícita, tudo a apontar o réu como pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...)" (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)" (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO

DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

Note-se, ainda, que o réu nada indicou de real para colocar dúvidas sobre a atuação dos policiais militares, pois a abordagem foi de rotina, em decorrência do patrulhamento de rotina, em local conhecido pela traficância ilícita, e os milicianos sequer o conheciam.

O depoimento dos agentes públicos colhido em audiência convence. O cotejamento dos depoimentos prestados pelos agentes da lei, nas duas fases da persecução penal, demonstrou que seus relatos foram convergentes e coerentes. Seus depoimentos, alinhados com a prova documental e pericial carreada, se mostraram perfeitamente válidos e devem ser acolhidos.

Não convence o teor do depoimento das testemunhas de defesa Thais e Tamyra. Embora tenham alegado que não viram o encontro de drogas em poder do acusado, observo que os policiais militares relataram exatamente o contrário, tanto que o prenderam em flagrante delito após tentar disfarçar sua presença no local ao se aproximar de um popular e danificar o seu telefone celular antes de ser abordado, tendo em seu poder vasta quantia em dinheiro e entorpecentes.

As testemunhas de defesa não afastam a credibilidade e precisão do que foi narrado pelos agentes públicos em todas as oportunidades em que foram ouvidos. Ademais, o testemunho dos policiais militares vem corroborado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudo pericial.

Aliás, no caso de acolhimento da versão do acusado (de que o entorpecente foi "plantado"), seria dada razão a tese de que os agentes públicos, de algum modo, adquiriram as drogas, colocaram os entorpecentes na sacola e, por fim, encenaram uma situação de flagrante delito para efetuar a prisão do réu durante patrulhamento de rotina.

A mencionada tese, além de inverossímil, carece de substrato fático probatório mínimo que lhe corrobore. Afinal, se as testemunhas arroladas pelo acusado não viram o encontro das drogas apreendidas em poder do agente, também não viram os guardas "plantando" o material no local da prisão.

Com o devido respeito ao entendimento da combativa Defesa, após todo o processado, não se extrai qualquer razão lógica e plausível de suposta armação dos policiais militares para incriminar o denunciado, de modo a aponta-lo injustamente como autor do grave crime de tráfico de drogas.

No mais, a Defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato dos agentes públicos para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

Portanto, a prova oral acusatória convence e fica acolhida.

E não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Por se tratar de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

“(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)” (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais dos artigos 59 do Código Penal e 42, da Lei nº 11.343/2006 são favoráveis ao réu, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência específica (cf. Autos nº 0008043-43.2017.8.26.0320 – trânsito em julgado em 10/02/2020 – fls. 38/40), de modo que exaspero a pena em 1/6, totalizando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não se conhece qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à reincidência por parte dos tribunais superiores, muito menos a necessidade de certidões cartorárias específicas para esse fim, anotando-se que a folha de antecedentes se presta para tanto.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitiva praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE – REINCIDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE – Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Na terceira fase, não reconheço a existência de bis in idem, não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei, tendo em vista que o acusado é reincidente

específico, em conformidade com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU REINCENTE. ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL. APLICAÇÃO NOS TERMOS DO DOS ARTS. 59 E 33, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (...) 2. Tratando-se de Paciente reincidente, não faz jus à aplicação da minorante inserta no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06, nem tampouco resta caracterizado bis in idem diante da utilização da reincidência como agravante genérica e como fundamento para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, aplicável apenas ao réu primário e de bons antecedentes. Precedentes (...) 4. Ordem de Habeas Corpus denegada." (STJ, HC 231.511/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 23/08/2013).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, REINCENTE. AGRAVANTE. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM NEGADA. 1. O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 2. Reconhecida pelo Colegiado Estadual a reincidência específica do paciente, não há como aplicar a minorante, porquanto não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. 3. Não há ilegalidade na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica. 4. Ordem denegada". (STJ, HC 147.271/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 30/05/2012).

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS SEUS REQUISITOS. REINCENTE. AGRAVANTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. I - Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois expressamente reconhecido na r. sentença condenatória que o paciente, por ser reincidente, não preenche os requisitos legais. II - Dentro dos limites legais, uma vez configurada a reincidência, a agravante deve ser aplicada. III - Não resta caracterizado bis in idem na utilização da reincidência como causa ensejadora da não aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como agravante da pena, ante expressa previsão legal. Habeas corpus denegado". (STJ, HC 148.575/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010).

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno a pena acima definitiva.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, sobretudo pela natureza e quantidade das drogas em discussão, sem reconhecimento do redutor, além de ser reincidente específico.

Regime diverso do fechado para quem não faz jus ao redutor legal seria de extrema benevolência, por se tratar de crime assemelhado a hediondo.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006, além do quantum fixado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar ROGER MOREIRA BASTOS, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no seu menor valor, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram a prisão, em especial, a necessidade de garantir a ordem pública, ante as nefastas consequências do tráfico de drogas para a sociedade em geral e a probabilidade concreta de solto, voltar a praticar o comércio espúrio de drogas, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido, anotando-se que é reincidente específico.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida, com as cautelas de praxe, pela qual representou a autoridade policial.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, porquanto fruto da traficância ilícita.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados. P.R.I.

Limeira, 18 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA